

1500098-67.2021.8.26.0585

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Comarca: Mirante do Paranapanema

Foro: Foro de Mirante do Paranapanema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... pela desclassificação do delito de tráfico para o delito de uso de entorpecentes (art. 28, da Lei nº 11.343/06), ou, ainda, a desclassificação para o crime previsto no parágrafo 3º, do artigo 33, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) e a fixação da pena em seu patamar mínimo, com aplicação da redução prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirante do Paranapanema

Foro de Mirante do Paranapanema

Vara Única

Rua Maria Lúcia Rodrigues de Almeida, 455, Mirante do Paranapanema-SP - cep 19260-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500098-67.2021.8.26.0585 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500098-67.2021.8.26.0585

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2132745/2021 - DEL.POL.MIRANTE

PARANAPANEMA, 17938522 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA, 351/21/303 - DEL.POL.MIRANTE

PARANAPANEMA, 2132745 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAN BARBOZA GOBBI e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal em face de JHONATAN BARBOZA GOBBI e HEDICLEY TIMOTIO SEGOBIA DA SILVA, qualificados nos autos, por violação ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29,

“caput”, do Código Penal, isto porque, no dia 15 de julho de 2021, às 18:00 horas, na Rodovia Olímpio Ferreira da Silva, Km 50, nesta cidade e Comarca de Mirante do Paranapanema/SP, agindo em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, adquiriram, transportaram e traziam consigo, para fins de entrega a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas consistentes em 30 (trinta) comprimidos de “ecstasy” (Metilenodioxianfetamina/Tenanfetamina – MDA), conforme auto de constatação preliminar (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21) e laudo pericial (fls. 119/121).

Segundo a denúncia, apurou-se que pessoas não identificadas encomendaram a compra de drogas com JHONATAN BARBOZA que, por sua vez, mancomunou-se com HEDICLEY TIMÓTIO e se deslocaram até a cidade de Presidente Prudente com a motocicleta Honda/CG Titan, placa CDR-5120, Teodoro Sampaio-SP, onde adquiriram de terceira pessoa não identificada as drogas acima mencionadas. Durante o trajeto de retorno, os denunciados foram abordados por policiais militares, que contavam com informações de que eles estariam envolvidos com o tráfico de drogas. É certo que, durante revista pessoal, os policiais localizaram as drogas em poder de JHONATAN. Caracterizada a situação flagrancial, JHONATAN e HEDICLEY foram presos em flagrante delito.

Descreve, finalmente, a inicial acusatória, que as circunstâncias, quantidade, natureza das drogas e conteúdo das mensagens do celular apreendido, demonstram as drogas destinavam-se à posterior entrega ao consumo de terceiros (tráfico de drogas).

Os acusados foram apresentados em Audiência de Custódia e, após as manifestações do digno representante do Ministério Público e do douto Defensor Público, o auto de prisão em flagrante foi homologado, deliberando-se pela conversão da prisão em flagrante do indiciado Jhonatan Barboza Gobbi em prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória sem fiança, com aplicação de medidas cautelares prevista no artigo 319, do Código de Processo Penal, ao indiciado Hedicley Timotio Segobia da Silva (fls. 82/92).

Atendendo ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019, foi revisada a prisão do acusado Jhonatan Barboza Gobbi em 23/08/2021, 18/02/2022 e 05/07/2022, deliberando-se pela manutenção da prisão preventiva, conforme r. Decisões de fls. 160/161, 212/214 e 290/291.

Os acusados foram regularmente notificados e apresentaram defesa preliminar (fls. 181/183 – Hedicley Timotio e fls. 232/235 – Jhonatan Barboza).

A denúncia foi recebida em 20/05/2022 (fls. 244/246).

Designou-se audiência de instrução (fls. 389/392), oportunidade em que se realizou o interrogatório dos acusados e a inquirição das testemunhas arroladas em comum pela acusação e defesas (fls. 433/435 – videoconferência/mídia importada para os autos).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência do pedido, nos exatos termos da inicial acusatória (fls. 441/445).

A defesa do réu Hedicley Timotio Segobia da Silva, por seu turno, postulou a absolvição, alegando a ausência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou pela desclassificação do delito de tráfico para o delito de uso de entorpecentes (art. 28, da Lei nº 11.343/06), ou, ainda, a desclassificação para o crime previsto no parágrafo 3º, do artigo 33, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) e a fixação

da pena em seu patamar mínimo, com aplicação da redução prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e o reconhecimento da atenuante de confissão (art. 65, III, alínea “d”, CP), bem como a primariedade do agente. Por fim, postulou que o réu tenha direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime aberto para cumprimento da pena a ser aplicada (fls. 449/462).

Já a defesa do corréu Jhonatan Barboza Gobbi, postulou o acolhimento da tese de desclassificação do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas, para o §3º, do artigo 33 da referida Lei. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena em seu patamar mínimo, compensando-se a agravante de reincidência com a atenuante da confissão, e a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão punitiva deduzida na presente ação é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), autos de constatação preliminar (fls. 10/11), boletim de ocorrência (fls. 14/17), autos de exibição e apreensão (fls. 21/28), pelo laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 122/124) – que detectou a presença da substância entorpecente “Metilenodioxianfetamina/Tenanfetamina (MDA)”, constante na Lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), pelo auto de análise de aparelho celular (fls. 137/146), pelo laudo pericial (fls. 311/373), bem como pela prova oral produzida.

Igualmente certa é a autoria.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu Jhonatan Barboza Gobbi negou a prática do delito a ele imputado. Disse que ele e alguns amigos “ficaram sabendo que ia ter uma festa” e, como usam “ecstasy” nessas festas, se juntaram e fizeram uma “vaquinha” para adquirir as drogas. Alegou que, como ninguém foi buscar o entorpecente, mandou mensagem para Hedcley e o convidou para irem até a cidade de Presidente Prudente para buscarem “umas balas”, sendo certo que pagou o combustível utilizado para abastecer a motocicleta de Hedcley. Após adquirirem os entorpecentes, retornaram para Teodoro Sampaio e, durante o trajeto, foram abordados por Policiais Militares. Disse que, ao ser indagado pelos Policiais, lhes afirmou que não comercializava entorpecentes e que as drogas que estavam em seu poder se destinavam a consumo próprio e de seus amigos. Relatou já ter sido processado anteriormente por tráfico de drogas e que conheceu Hedcley durante o período em que trabalhou com serviço de pintura de uma escola em Teodoro Sampaio. Por fim, disse que daria “uma bala” para Hedcley, visto que, em data pretérita, Hedcley lhe forneceu uma porção deste entorpecente e que só foram buscar a droga porque nenhum dos amigos dele se ofereceu para ir em seu lugar (videoconferência realizada por meio do sistema Microsoft Teams).

Em seu interrogatório judicial, o corréu Hedcley Timotio Segóbia da Silva, também negou a prática do delito a ele imputado. Disse que foram para Presidente Prudente e estava ciente de que iriam comprar “umas balas”, sendo certo que Jhonatan pagou o combustível utilizado na viagem e lhe daria um dos comprimidos. Disse que o entorpecente não era destinado à venda, alegando que fizeram uma “vaquinha” para adquirir a droga, a qual seria consumida por eles e alguns amigos em uma festa. Por fim, disse que não estava presente no momento em que Jhonatan adquiriu o entorpecente em Presidente Prudente (videoconferência realizada por meio do sistema Microsoft Teams).

No entanto, as versões dos réus restaram isoladas, estando em conflito com as demais provas colhidas.

O Policial Militar Armando Noriyoshi Osaiki, testemunha arrolada pela acusação, confirmou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que, no dia dos fatos, estavam se deslocando para Teodoro Sampaio-SP e, próximo ao trevo de Cuiabá Paulista, avistaram os réus em uma motocicleta, a qual era conduzida por Hedcley, e Jhonatan, conhecido como "Goby" era o passageiro. Disse que, como possuíam informações pretéritas de que eles realizavam tráfico de drogas na cidade de Teodoro Sampaio, deliberaram por aborda-los e lograram êxito em localizar as drogas acima citadas (comprimidos de cor azul e amarela) em poder de Jhonatan. Ao ser indagado, este réu afirmou que as drogas seriam revendidas em uma festa que seria realizada em uma chácara em Teodoro Sampaio, sendo certo que os entorpecentes foram previamente encomendados. Disse, ainda, que o corréu Hedcley lhes confirmou que ele e Jhonatan foram até a cidade de Presidente Prudente para adquirir as drogas. Relatou que as informações que possuíam de que os réus comercializavam entorpecentes lhes foram repassadas anteriormente por outras equipes policiais, informações estas, que descreviam o "modus operandi", nomes, características físicas dos indivíduos e veículos eventualmente utilizados por eles. Por fim, confirmou que o réu Jhonatan, espontaneamente, admitiu que as drogas seriam comercializadas em uma festa, e que foram encomendadas anteriormente. Por fim, soube que a festa onde seriam comercializados os entorpecentes realmente aconteceu (videoconferência realizada por meio do sistema Microsoft Teams).

Em idêntico sentido, o depoimento prestado pelo Policial Militar Marcos Cordeiro Vieira, confirmando que os réus, no momento da abordagem, assumiram a propriedade dos entorpecentes apreendidos e afirmaram que se destinavam à venda para terceiros em uma festa, acrescentando que o réu Jhonatan usou a expressão "que o pessoal queria ficar meio na brisa" e que alguns deles já havia pago antecipadamente pelo entorpecente, versão também confirmada pelo corréu Hedcley (videoconferência realizada por meio do sistema Microsoft Teams).

Oportuno salientar, que o testemunho de um policial goza de presunção de veracidade, além de ser extremamente valioso na elucidação de um delito, uma vez que participou diretamente do flagrante, tendo este ocorrido na perfeita legalidade.

A respeito da validade e credibilidade de depoimentos prestados por policiais, trago à baila jurisprudência no sentido de que:

"PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam declarações como testemunhas em processo criminal, posto que ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo não provido" (Apelação criminal nº 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos Almeida, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).

No mesmo sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"(...) a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso (...)" - (HC 477.171/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 22/11/2018). (negritei)

Pois bem.

Os policiais foram uníssonos ao confirmar que possuíam informações de que os réus praticavam a mercancia de drogas. No dia dos fatos, coincidentemente, avistaram a motocicleta descrita nas informações, razão pela qual deliberaram por abordar os acusados, oportunidade em que foi apreendida relevante quantidade de drogas em poder deles, frise-se, 30 (trinta) comprimidos de "ecstasy", os quais foram previamente encomendados por terceiros.

No laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 122/124), a senhora Perita constatou o seguinte: "A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e, foi DETECTADA a presença da substância Metilenodioxianfetamina/Tenanfetamina (MDA), constante na Lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)".

Assim, diante de todo esse conjunto probatório, não existem dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, restando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do tráfico de entorpecentes praticado pelos réus.

Ademais, conforme bem mencionado pelo digno representante do Parquet à fl. 443: "Ressalta-se que, consoante se verifica auto de análise de aparelho celular de HEDICLEY às fls. 137/146, os réus se mancomunaram para a adquirir drogas na cidade de Presidente Prudente, para posterior entrega a terceiros".

Já no laudo pericial de fls. 311/373, especialmente às fls. 327/328: "Hedicley comenta com "Polaconha" que vai a Presidente Prudente buscar "umas bala", junto com "Jhow", que se trata de Jhonatan Barboza" e ambos combinam de ir a Presidente Prudente (pp) buscar umas "@", e ainda Hedicley pergunta a Jhow se ele sabe o lugar onde buscaram a "bala".

Às fls. 364/368, o Perito informa ainda que: "na galeria de imagens foram encontradas fotos relacionáveis ao fato, contendo imagens similares a droga conhecida como "bala", e também de quantidade em papel moeda nacional" e, Jhonatan e um terceiro, identificado como "Renan Pp", "no dia 09/05, às 13:30 entram em diálogo e "Jhow" pergunta se "Renan Pp" pegaria e traria para ele umas coisas que ele consegue em Presidente Prudente. Renan Pp pergunta o que seria? "Jhow" fala que é 'umas @, bagulho, negócio', que eles vão fazer uma festa dia 22 e querem ficar "locão".

Descreve, ainda, diálogos travados entre os réus: "no dia 29/03/2021 às 10:45, "Jhow" pergunta a "Edglei" quanto está 25 gramas. Edglei responde que está 100. Na sequência do diálogo, que ocorre dia 30/03/2021, às 11:24, "Jhow" pergunta a "Edglei" se ele não poderia levar o bagulho ali na João Ribeiro" (fls. 368/369).

Por fim, o Perito descreve que, em diálogo travado entre Jhonatan "Jhow" e um terceiro, identificado como "Cadu", no dia 07/05/2021 às 18:35, onde: "Jhow fala pra "Cadu" pra ele não esquecer de levar os 120, dele e do "Arruda", que o cara já está com os bagulho na mão" (fl. 371)", o que leva à ilação de que estavam tratando sobre venda de entorpecentes.

Desta feita, forçoso concluir, que as informações pretéritas de que os réus praticavam a mercancia de drogas restaram cabalmente comprovadas, inclusive pelo fato de terem sido surpreendidos transportando as drogas.

Observo, que a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da venda da droga, restando bem delineada nos autos, a configuração do delito nas modalidades de "transportar, trazer consigo e entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". A quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias que ensejaram a abordagem dos réus, não deixam dúvidas a respeito da traficância.

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

E, ainda. Para caracterização do tráfico de entorpecentes não há necessidade de que se apresente na polícia ou em Juízo alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que o réu seja flagrado na prática de algum ato típico de efetiva alienação da droga, bastando que o acusado efetue uma das condutas previstas no tipo penal.

De outra banda, não merecem acolhida os pedidos formulados pelas combativas defesa, postulando a desclassificação da conduta praticada pelos acusados para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

É cediço que, para fins de configuração do tráfico, o Juiz não deve se ater apenas à quantidade de drogas, mas também se atentar aos demais elementos, como forma de acondicionamento da substância, variedade e circunstâncias da flagrância.

Nesse sentido, destaco:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. Ausência de pedido de perícia na defesa preliminar e durante a instrução. Ausência de elementos que justifiquem a realização de exame. Mérito. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do acusado. Desclassificação. Impossibilidade. Quantidade de droga, forma de acondicionamento, circunstâncias do crime e da prisão que revelam a incompatibilidade de transporte para mero uso e evidenciam a venda e a destinação à mercancia. Penas e regime bem aplicados NEGADO PROVIMENTO AO APELO". (TJSP; Apelação 0001323-43.2016.8.26.0628; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taboão da Serra - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018). (negritei)

E mais. O crime de tráfico de entorpecentes, para sua tipificação, não exige a prova do elemento subjetivo do tipo.

VICENTE GREGO FILHO, analisando o crime na lei anterior, afirma que o tipo subjetivo do crime de tráfico não prevê o fim especial de agir, esgotando-se no dolo natural. (Tóxico prevenção-repressão - São Paulo: Saraiva - 8ª Ed. - p. 98).

Apreciando a questão, também sob a vigência da Lei 6.368/76, MENNA BARRETO, "de modo que, em não se tratando de uso próprio, como verificaremos ao analisar o artigo 16, o fato de adquirir, guardar ou mesmo trazer consigo entorpecente ou substância que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito. O crime é de perigo abstrato e a presunção legal de dano à pessoa e à coletividade está plenamente justificada pelos malefícios que os tóxicos causam até mesmo à própria "integridade da estirpe", conforme registra o Professor E. Magalhães Noronha. O bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, mais particularmente a saúde pública, sendo certo que o elemento subjetivo do delito está na vontade livremente dirigida no sentido da prática de alguma das ações previstas no tipo, caracterizando-se, destarte, o dolo como genérico". (Lei de Tóxico - comentários artigo por artigo - Freitas Bastos - 5ª Ed. - p. 73).

Assim, aplica-se ao crime de tráfico de entorpecentes da Lei 11.343/06 a mesma explicação, visto a similitude do tipo penal da lei anterior com o da lei atual.

Neste sentido, o crime de tráfico de entorpecentes, em ambas as leis, é um tipo misto alternativo, onde a narrativa se ajusta ao que está entre as formas

elencadas. Assim, as condutas de trazer consigo, guardar, transportar etc. não exigem especial fim de agir.

Desta forma, nas condutas presentes no porte e no tráfico, como trazer consigo, existindo elementos que excedem ao dolo, os chamados elementos subjetivos do injusto (no caso a finalidade específica da destinação ao consumo pessoal), estar-se-á configurado o porte. Não existindo tal finalidade específica, ou seja, não se destinando exclusivamente ao consumo pessoal, não importando qual a finalidade, tem-se por configurada a figura do tráfico de entorpecentes.

Este é o entendimento adotado pelo E. Supremo Tribunal Federal:

“Tráfico de entorpecente. Indícios. Inexistência de causa para condenação. Art. 157 e 239 do CPP. Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexos com o fato a ser provado seja lógico e próximo. O crime de tráfico ilícito de entorpecente não exige o dolo específico, contentando-se, entre outras, com a conduta típica de “ter em depósito, sem autorização”. (STJ - HC 70344/RJ - rel. Min. Paulo Brossard - DJU 22.10.1993). (negritei)

Também é este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória”. (STJ - RESp 1361484/MG - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - Sexta Turma - j. 10/06/2014).

Por todo o exposto, existindo provas de que o entorpecente apreendido em poder dos réus se destinava à entrega para terceiros, conclui-se que o contexto probatório é harmônico e coerente, robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório, não restando dúvidas de que praticaram o delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

01 - Em relação ao réu Jhonatan Barboza Gobbi:

Atentando às circunstâncias dos artigos 59 e 68 do Código Penal e, considerando os maus antecedentes ostentados por este réu (fls. 250/253 e 280/282), fixo a pena acima do mínimo legal 1/6, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (Processo Criminal 1500125-21.2019.8.26.0585 - fls. 280/281), de modo que a pena será aumentada de 1/6, totalizando então 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Na terceira e última fase da dosimetria, ausente causas de aumento da pena. No entanto, diante da reincidência do réu e, uma vez que há nos autos, especialmente no laudo pericial realizado nos aparelhos telefônicos dos acusados (fls. 311/373), evidências de que se dedicavam a atividades criminosas, deixo de aplicar a causa de

diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Torno a pena definitiva diante da ausência de outras circunstâncias modificadoras.

O valor de cada dia-multa, fixado no mínimo legal, corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo da infração, devidamente atualizado.

02 - Em relação ao corréu Hedicley Timotio Segóbia da Silva:

Atentando às circunstâncias dos artigos 59 e 68 do Código Penal e, considerando sua primariedade, fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Na terceira e última fase da dosimetria, ausente causas de aumento da pena. No entanto, uma vez que há nos autos, especialmente no laudo pericial realizado nos aparelhos telefônicos dos acusados (fls. 311/373), evidências de que se dedicavam a atividades criminosas, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Torno a pena definitiva diante da ausência de outras circunstâncias modificadoras.

O valor de cada dia-multa, fixado no mínimo legal, corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo da infração, devidamente atualizado.

DECISÃO

Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na presente ação penal para:

a) CONDENAR o réu JHONATAN BARBOZA GOBBI, como incurso nos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no seu valor unitário mínimo, dada a situação econômica do sentenciado;

b) CONDENAR o corréu HEDICLEY TIMOTIO SEGÓBIA DA SILVA, como incurso nos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no seu valor unitário mínimo, dada a situação econômica do sentenciado.

Diante da quantidade de pena aplicada e, considerando que há nos autos, especialmente no laudo pericial realizado nos aparelhos telefônicos dos acusados (fls. 311/373), evidências de que se dedicavam a atividades criminosas, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, ex vi do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII). Aliás, embora não desconheça a declaração incidental de inconstitucionalidade do dispositivo mencionado no julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do HC n. 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, entendo que, por possuir eficácia "inter partes", o controle de constitucionalidade difuso exercido pelo Supremo Tribunal Federal não vincula as Instâncias inferiores, apenas produzindo efeito naquele julgamento em especial.

Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos do art. 44, incisos I e II, do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja porque o art.

5º, XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inc. LI. Frise-se que a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as hipóteses excludentes do regime de substituição de penas, contempladas no art. 44 do Código Penal, têm como suporte unicamente o critério do legislador ordinário; já a inconversibilidade das penas quando a condenação decorre do tráfico ilícito de entorpecentes tem por si a vontade do constituinte, que em dois momentos destacou a importância da repressão a esse crime, no art. 5º, XLIII e LI, da CF (Arguição de Inconstitucionalidade/HC 120.353, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Ari Pargendler, DJe: 18.12.2009). Por fim, o crime de tráfico de entorpecentes, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem. Assim, a concessão dos citados benefícios, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (art. 59 do Código Penal), gerando ofensa ao disposto no art. 44, inc. III, do CP, e verdadeira sensação de impunidade a esta pequena cidade do interior.

Em relação ao réu JHONATAN BARBOZA GOBBI, diante do fato de ter respondido ao processo no cárcere e, levando-se em consideração o disposto no artigo 59, da Lei 11.343/06, não poderá apelar em liberdade, mesmo porque presentes estão os requisitos da custódia cautelar, conforme amplamente evidenciado nos autos.

Nesse sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça: "inaplicável, a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória (RHC 177 - RJ- 5 Cfm. do STJ, v.u., rel. M. Assis Toledo, DJU, de 30.10.89). Pois, seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar, viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelos mais" (RT 504/339). (negritei)

Deixo de lhe aplicar, ainda, o disposto no art. 387, §2º, do CPP, uma vez que ausentes elementos suficientes nos autos para a sua apreciação.

É certo que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, determina que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, seja computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Contudo, a colocação deste réu em regime mais benéfico fica condicionada à demonstração de que ostenta bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, bem como à verificação de que não se encontra preso, provisória ou definitivamente em razão de outro processo, cabendo ao Juízo de Execução proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos artigos 66, inc. III, a, e 111, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Esse é o entendimento que prevalece no E. Tribunal de Justiça: "Aplicação da detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Inviabilidade. Ausência de elementos suficientes para concessão da benesse. Pleito que deve ser submetido ao Juízo das Execuções Criminais." (TJSP; Apelação 0008393-56.2017.8.26.0635; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/01/2019; Data de Registro: 16/01/2019).

Em relação ao corréu HEDICLEY TIMOTIO SEGÓBIA DA SILVA, em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, observadas as medidas cautelares que lhe foram impostas (fls. 82/92) e, ainda, considerando que respondeu ao processo solto condicionalmente, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Nesse sentido, o entendimento do E. Tribunal de Justiça:

"É certo que o apelo em liberdade, tendo o paciente respondido ao processo preso, quando existiam somente indícios de autoria, seria um contrassenso conceder a ele, depois de condenado, permissão para recorrer solto. Já está pacífico na jurisprudência dos EE. Tribunais Superiores que, salvo raríssimas exceções, plenamente justificadas, o normal é o réu, ao recorrer, permanecer na situação em que se encontra, isto é, preso, se custodiado cautelarmente e solto, se não." (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - HC n.0080825-14.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto - Rel. Des. FERNANDO MIRANDA, j.19/07/2012). (negritei)

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos nos autos em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Recomende-se o réu Jhonatan Barboza Gobbi na prisão em que se encontra e, transitado em julgado, expeça-se mandado de prisão em desfavor do corréu Hedicley Timotio Segóbia da Silva.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

Caso ainda não tenha sido realizada até a presente data, autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, nos termos dos artigos 50, §3º e 50-A da Lei Antidrogas, reservando-se amostra para eventual contraprova. Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, nos termos do art. 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Custas ex legis.

P.R.I.

Mirante do Paranapanema, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA